

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제01절 부작위위법확인소송>

[기출][2014-2]부작위위법확인소송에서의 부작위의 의의 및 성립요건

《[문제2] 부작위위법확인소송의 본안판단 요건으로서 부작위의 의의와 성립요건을 설명하시오. (25점)》

<문제2> 부작위위법확인소송에서의 부작위의 의의 및 성립요건

I. 문제 제기

- "행정소송법 제4조"는 항고소송의 유형으로서 취소소송, 무효등확인소송과 함께 부작위위법확인소송을 규정하고 있다. 부작위위법확인소송은 행정청이 당사자의 신청에도 불구하고 상당한 기간 내에 처분을 하지 않는 경우, 그 부작위가 위법함을 확인하는 소송이다. 이는 국민의 신청권을 실질적으로 보장하고, 행정의 소극적 태도로부터 권리를 보호하기 위한 중요한 제도이다. 그러나 부작위위법확인소송이 성립하기 위해서는 단순히 처분이 없다는 사실만으로는 부족하며, 법률상 일정한 요건을 충족해야 한다. 이하에서는 본 소송의 본안판단 요건으로서 부작위의 의의와 성립요건을 구체적으로 설명한다.

II. 부작위의 의의

- 부작위란 행정청이 국민의 신청에 대하여 응답해야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 상당한 기간 내에 아무런 처분을 하지 않는 상태를 의미한다. 이는 단순히 행정청의 소극적 태도와 구별된다. 즉, 법률상 응답의무가 없는 경우나, 사실상 준비단계에 불과한 미행위는 부작위에 해당하지 않는다. 따라서 부작위는 신청에 대한 응답의무가 존재함에도 이를 이행하지 않은 상태라는 점에서, 법률적·절차적 의미를 갖는다.

III. 부작위의 성립 요건

1. 행정청의 존재

- 부작위는 행정권 행사주체로서 권한 있는 행정청이 존재해야 한다. 권한 없는 기관의 불응이나 단순한 사실상 태만은 부작위의 대상이 될 수 없다.

2. 당사자의 신청 존재

- 부작위위법확인소송은 당사자의 신청을 전제로 한다. 이는 행정청이 법률상 또는 조리상 응답하여야 할 신청이어야 하며, 추상적 진정이나 단순 문의 등은 해당하지 않는다. 신청은 서면·구두를 불문하나, 법령에서 일정한 형식을 요구하는 경우 이를 갖추어야 한다.

3. 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무 존재

(1) 기속행위의 경우

- 법령에 따라 행정청이 일정한 요건을 충족하면 반드시 허가·인가 등 처분을 하여야 하는 경우, 신청에 대하여 행정청은 기속적으로 응답할 의무를 진다. 따라서 이 경우 응답하지 않는다면 곧바로 부작위가 성립한다.

(2) 재량행위의 경우

- 재량행위의 경우에도 일정한 범위 내에서 행정청은 신청에 응답해야 할 법률상 의무를 부담한다.

① 무하자재량행사청구권

- 신청인은 행정청이 재량을 행사함에 있어 하자 없는 판단을 할 것을 청구할 권리를 가진다. 따라서 재량행위라고 하여 행정청이 전혀 응답하지 않는 것은 허용되지 않는다.

② 재량권 0으로 수축

- 법령의 목적과 보호이익, 구체적 사정을 종합하여 행정청의 재량이 사실상 0으로 수축되는 경우에는 사실상 기속행위와 동일하게 응답의무가 발생한다.

(3) 판례의 경향

- "대법원"은 기속행위뿐 아니라 재량행위에 있어서도 응답의무를 인정하여 부작위 성립을 긍정하고 있다. 예컨대, 행정청이 일정한 요건을 충족한 건축허가 신청을 장기간 처리하지 않은 경우 부작위를 인정하였다. 이는 국민의 권리보호와 행정책임성을 강화하려는 입장이다.

4. 상당한 기간의 경과

- 부작위는 신청 후 상당한 기간이 경과하여야 성립한다. 여기서 상당한 기간이란 구체적 사안에 따라 판단되며, 법령에 처리기간이 정해진 경우 그 기간을 기준으로 한다. 별도의 규정이 없는 경우에도 사회통념상 행정청이 응답할 수 있는 합리적 기간이 도과해야 한다.

5. 처분 또는 부작위 상태의 지속

- 부작위가 성립하기 위해서는 신청 후 행정청의 불응 상태가 계속되어야 한다. 만일 소 제기 전에 행정청이 처분을 한 경우, 더 이상 부작위 상태가 아니므로 부작위위법확인소송은 부적법하게 된다.

IV. 결론

- 부작위위법확인소송의 본안판단 요건으로서 부작위가 성립하기 위해서는, ① 권한 있는 행정청이 존재하고, ② 당사자의 적법한 신청이 있으며, ③ 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 존재하고, ④ 상당한 기간이 경과하였음에도 불구하고, ⑤ 처분이 없는 상태가 계속되어야 한다. 특히 재량행위의 경우에도 무하자재량행사청구권 및 재량권 0으로의 수축 이론을 통해 응답의무가 인정됨을 "판례"는 명확히 하고 있다. 따라서 부작위위법확인소송은 단순히 행정청의 소극적 태만을 다루는 것이 아니라, 법률상 응답의무 위반을 전제로 하여 국민의 권익을 보호하는 제도라는 점에서 의의가 크다.

<재량권이 0으로 수축>

- 원칙적으로 재량행위인 경우에도, 특정 사안에서 위험이 중대하고 다른 수단이 없으면 행정청의 선택지가 사라져 특정 조치를 해야 할 의무로 바뀐다는 개념